

1500356-82.2021.8.26.0551

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RAFAEL DA CRUZ GOUVEIA LINARDI

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2227683/2021 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 19764137 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO,

1939/21/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2227683 - DISE- ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

3ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500356-82.2021.8.26.0551 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500356-82.2021.8.26.0551

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2227683/2021 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 19764137 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO,

1939/21/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2227683 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 1939/21/923

- DISE- DEL.SEC.LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Gustavo Leandro dos Santos

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RAFAEL DA CRUZ GOUVEIA LINARDI

Vistos.

O réu GUSTAVO LEANDRO DOS SANTOS encontra-se denunciado pela suposta prática do delito capitulado pelo art. 33, caput, c.c. art. 40, inciso III, ambos da Lei nº

11.343/06.

Consta da denúncia que, na data de 20 de agosto de 2021, por volta das 16h30min, na Rua Valter Batista dos Santos, próximo ao numeral 1549, Parque Nossa Senhora das Dores IV, nesta cidade e Comarca de Limeira, trazia consigo, e mantinha em depósito, para ser entregue a consumo de terceiros, em atividade de tráfico ilícito, aproximadamente 2,56g (dois gramas e cinquenta e seis centigramas), divididas em 18 microtubos plásticos de Cocaína, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme os fatos narrados na denúncia a qual me reporto.

Recebida a denúncia (141/143), devidamente citado (fls. 160), o réu apresentou defesa prévia (fls. 136/140).

Regularmente processado, foram ouvidas as testemunhas arroladas e promovido o interrogatório (fls. 168/169).

Em alegações finais, o Ministério Público requereu procedência da denúncia, ante a existência de prova suficiente da autoria e materialidade.

A defesa por sua vez, também em memorial, sustentou em preliminar a ilegalidade da atuação da guarda municipal. No mérito, ser hipótese de absolvição, em virtude da insuficiência probatória, requereu também desclassificação para art. 28 da Lei 11.343/06.

É a síntese do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Inicialmente, analisando-se as circunstâncias do caso em concreto, não vislumbro ilegalidade na conduta dos guardas civis municipais, que possa comprometer a idoneidade das provas obtidas por meio da abordagem realizada.

Conforme estabelece o artigo 144, da Constituição Federal, a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, e é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, por meio de diversos órgãos.

Especificamente no tocante à atribuição da guarda municipal, está compreendido não apenas o patrulhamento preventivo, como o uso progressivo da força, conforme disposto no artigo 3º, incisos III e V, da Lei Federal nº 13.022/14, competindo-lhe, ainda, “colaborar, de forma integrada com os órgãos de segurança pública, em ações conjuntas que contribuam com a paz social” e “encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito, o autor da infração” conforme disposto no artigo 5º, incisos IV e XIV, da referida lei.

No caso em apreço, os guardas civis realizavam patrulhamento de rotina, e no momento em que transitavam pelo local, verificaram atuação suspeita do acusado em atitude reveladora de traficância, inexistindo impedimento para que a promovessem a prisão em flagrante, com fundamento no artigo 301, do Código de Processo Penal, pois trata-se de faculdade atribuída a qualquer cidadão, considerando que ninguém pode ser compelido a quedar-se inerte diante de um ilícito.

Nesse sentido, os seguintes arestos do C. Superior Tribunal de Justiça:

"PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE PELA PRISÃO EM FLAGRANTE POR GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. INOCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 301 DO CPP. DOSIMETRIA. AUMENTO DA BASILAR. DIVERSIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENHIDAS, ALÉM DE ANTECEDENTES CRIMINAIS E

CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) II - No presente caso, com relação à alegada nulidade da prisão em flagrante realizada por guardas municipais, cumpre registrar que é assente nesta Corte Superior a orientação de que os integrantes da guarda municipal não desempenham a função de policiamento ostensivo. Contudo, também é firme o entendimento jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, "nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode prender quem esteja em flagrante delito, razão pela qual não há qualquer óbice à sua realização por guardas municipais. Precedentes" (HC n. 357.725/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 12/05/2017). Precedentes. III - Destarte, em situações de flagrante delito, como restou evidenciado v. aresto reprochado, bem como no auto de prisão em flagrante lavrado pela autoridade policial, a atuação dos agentes municipais está respaldada no comando legal do art. 301 do Código de Processo Penal. Ademais, no que tange ao pleito defensivo de reconhecimento da ilicitude das provas, verifica-se que o v. aresto vergastado afastou motivadamente a alegada nulidade da busca e apreensão pessoal, sob o fundamento de que havia fundadas suspeita para a referida diligência porquanto, em patrulhamento de rotina em local conhecido pelo tráfico de drogas (cracolândia), os guardas civis visualizaram o acusado em atitude suspeita, uma vez que tentou empreender fuga ao se deparar com a viatura, levando à abordagem que resultou na apreensão de entorpecentes de natureza extremamente deletéria. Precedentes. (...) Habeas corpus não conhecido". (STJ, HC 742941/SP, Relator Ministro Jesuíno Rissato, Quinta Turma, julgamento em 09/08/2022, DJe 16/08/2022). "PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. OFENSA AOS ARTS. 4º E 5º DA LEI 13.022/2014 E AO ART. 157 DO CPP. NÃO VERIFICAÇÃO. GUARDAS MUNICIPAIS. PRISÃO FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 2. VIOLAÇÃO DO ART. 386, III, DO CPP. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. ATIPICIDADE POR INSIGNIFICÂNCIA. NÃO VERIFICAÇÃO. CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS. 3. AFRONTA AO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. NÃO OCORRÊNCIA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REVERSÃO. SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O entendimento assentado pela Corte local encontra-se em consonância com a jurisprudência do STJ, que é no sentido da inexistência de óbice à realização de prisão, em situação de flagrância, por guardas municipais ou qualquer outra pessoa, não havendo falar, portanto, em ilicitude das provas daí decorrentes. 2. É possível a aplicação do princípio da insignificância na hipótese de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, em situação que denote a inexpressividade da lesão jurídica provocada, desde que não se trate de contexto que envolva a prática de outros delitos. O contexto dos autos envolve também o crime tráfico ilícito de drogas, o que impede a aplicação da mencionada benesse. 3. Encontra-se concretamente fundamentado o decote da causa de diminuição da pena, com base não apenas na expressiva quantidade de droga, mas também nas circunstâncias da prisão. Dessa forma, para desconstituir as conclusões da Corte de origem, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que não é possível na via eleita, haja vista o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento". (STJ, AgRg no AREsp n. 2.019.016/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 07/06/2022, DJe de 13/06/2022).

Ressalte-se, por fim, que a vingar uma interpretação excessivamente reducionista no que diz respeito aos limites da atuação da guarda municipal, ter-se-á como consequência inexorável a interrupção de relevantes projetos relacionados à segurança pública no âmbito dos municípios, tendo como exemplo a "Ronda Maria da Penha" existente nesta cidade de Limeira, onde as ações das polícias e da guarda civil são interconectadas, como forma de se prevenir e reprimir crimes praticados no âmbito da violência doméstica, havendo inclusive uso de aplicativos e dispositivos de segurança ("botão do pânico").

Portanto, desconsiderar toda a logística da atuação conjunta das instituições de segurança pública implicaria em enorme retrocesso, especialmente ante os esforços

promovidos por anos a fio no combate à violência contra a mulher, como se verifica no exemplo retromencionado.

Assim, rejeitada a matéria preliminar, passo ao exame do mérito.

A materialidade delitiva está plenamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 03/04), boletim de ocorrência (fls. 19/21), auto de exibição e apreensão (fls. 22), fotografias (fls. 23/25), laudo de constatação provisória (fls. 27/29), laudo de exame químico toxicológico (fls. 97/99) e pela prova testemunhal.

A autoria restou bem delineada, vejamos os depoimentos:

Perante a d. Autoridade Policial, GUSTAVO confessou que estava ajudando outra pessoa na venda de drogas, como "olheiro" (fl. 09).

Interrogado o réu, em juízo, tentou se eximir da responsabilidade apresentando uma versão diferente, onde afirmou que as porções de drogas localizadas na sua posse destinavam-se ao consumo pessoal. Disse que as outras drogas localizadas não eram suas. Alegou que não confessou o tráfico de drogas na Delegacia de Polícia, acabou por não ser devidamente interpretado.

Os guardas municipais Celio Roberto de Oliveira e seu colega de farda Gustavo Zanella Salgado Cesar narram que estavam em patrulhamento de moto, momento em que avistaram o réu no local dos fatos, mexendo em um buraco no muro e logo em seguida entregou algo ao motorista de um veículo que ali estava. Disse que ao abordarem o réu, encontraram junto a ele 70,00 reais e um sachê contendo substância branca aparentando cocaína e, ao averiguar o buraco encontraram mais 17 sachês idênticos ao encontrado com ele, contendo a mesma substância branca. Destacou que o acusado confessou o tráfico de drogas justificando-se que precisava pagar uma dívida.

As testemunhas puderam constatar o efetivo ato de mercancia por parte do réu, já que antes da abordagem, constatarem a comunicação prévia entre o acusado e um condutor de um veículo, a revelar traficância, até porque o local dos fatos é notoriamente conhecido como ponto de comércio ilícito de entorpecentes.

A quantidade de droga apreendida não é desprezível, e diante das circunstâncias concretas, mostra-se incompatível com a posse para uso próprio, sendo certo que a análise da prática do delito previsto no artigo 33 da Lei n. 11343 deve ser feita em conformidade com o contexto apresentado, de forma que o conjunto de elementos somados uns aos outros, por intermédio do raciocínio indutivo, faça "crescer o conhecimento do ser humano, unindo-se dados parciais para formar um quadro mais amplo" (NUCCI, CPP Comentado, p. 521, 9. Ed, RT).

Enfim, a prova colhida em contraditório mostra-se coesa e harmônica, inclusive com os indícios da fase inquisitorial.

Não há indicativo de abuso dos guardas, que realizaram a abordagem com fundamento em suspeitas plenamente justificadas, tanto que encontradas porções significativas de entorpecentes, tanto em posse, como também próximas ao réu, assim como indicado.

Note-se que uma pessoa parada num ponto de tráfico, mexendo em um buraco e logo em seguida interagindo com um condutor de veículo, não se trata de mero palpite aleatório dos policiais, tampouco preconceito.

No mais, não há qualquer indícios de que os guardas teriam "forjado" as porções, ou seja, obtido previamente a droga em outra ação e, de forma criminosa, imputado a posse ao acusado de forma gratuita, com o único propósito de incriminá-lo.

Sob este prisma, não se ignora que o relato de agentes estatais, naturalmente interessados diretamente na avaliação positiva de suas condutas, deva ser considerado com cautela pelo julgador.

No entanto, a bem da verdade, todo e qualquer testemunho ou relato deve sempre ser analisado com cuidado pelo juiz, uma vez que é bastante provável que, por exemplo, a vítima tenha a tendência de "enxergar" os fatos de modo mais favorável a si, ou que as testemunhas procurem tornar suas declarações o mais convincentes possível.

Dessa forma, deve sempre o magistrado proferir sua decisão de acordo com o chamado livre convencimento motivado, fundamentando-a nos diversos elementos dos autos, admitindo-se a condenação quando estes se mostrem harmônicos, não se prescindindo da existência de prova colhida em contraditório judicial.

No caso em tela, portanto, não se demonstrando interesse pessoal dos agentes no objeto da investigação, tendo suas declarações sido confirmadas, em essência, pelos demais indícios dos autos, havendo coerência e verossimilhança nos relatos, evidente que se pode levá-los em conta para um decreto condenatório.

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos". (HC nº 74.608-0-SP - Rel. Min Celso de Mello).

Portanto, consideradas todas as circunstâncias da prisão em flagrante, a localização das porções de drogas, a quantidade não desprezível apreendida em área conhecida como ponto de traficância, a forma como estavam acondicionadas, bem como a confirmação da venda presenciada pela negociação entre o acusado e o condutor de um veículo, tem-se como certa a prática da atividade de tráfico ilícito.

Assim sendo, indubitosa a necessidade da condenação do acusado pelo crime previsto no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Quanto às circunstâncias do crime, que são todos os aspectos objetivos relevantes que se fazem presentes ao redor do fato e que influíram na sua prática, tais como clima, tempo, lugar e modo de execução, tem-se que no delito de tráfico de entorpecentes, levando-se em conta o disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, no sentido de que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente, é de se reconhecer que a não muito alta quantidade de droga, mas suficiente para se ter, diante das circunstâncias do caso, como incompatível para o uso, não enseja a elevação da pena-base.

Desse modo, considerando-se os elementos analisados acima, fixo a pena-base no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de multa 500 (quinhentos) dias-multa

Na segunda fase da dosimetria, embora presente a atenuante menoridade, essa circunstância não pode incidir para conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

No tocante à majorante prevista no artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/06, entendo pertinente sua aplicação no caso em concreto, pois atuava nas proximidades de centro comunitário. Sendo assim, fixo a pena em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e pagamento de multa 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Por derradeiro, cumpre apreciar se faz ou não jus à causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, sendo que as passagens e condenações por atos infracionais equiparados ao tráfico (Autos nº 0007800-02.2017.8.26.0320, 0008658-96.2018.8.26.0320, 0008796-34.2016.8.26.0320, 0014987-95.2016.8.26.0320, 0024109-69.2015.8.26.0320 e 0024441-02.2016.8.26.0320 - fls. 33/34 e 122/123), para configurarem "dedicação permanente às atividades criminosas", devem ser apreciadas de acordo com as circunstâncias do caso em concreto.

Pois bem, em breve consulta, percebe-se que realmente o jovem enveredou-se na seara do tráfico à época da adolescência, sendo que entre os anos de 2015 e 2018 sofreu diversas imposições de medidas sócio-educativas.

No entanto, também se observa que completou a maioridade no dia 18.06.2020, e a última medida sócio-educativa foi encerrada em 17.12.2018, tendo sido preso nestes autos em 20.08.2021.

Portanto, é possível que no interregno entre a última medida sócio-educativa cumprida tenha se mantido na traficância, mas também é possível, por outro lado, que tenha se afastado por mais de dois anos, e retornado, por motivos de diversas ordens, havendo dúvida acerca da "permanência" justificadora do afastamento da causa minorante.

Assim, ante a situação dúvida, prudente dar solução mais favorável ao réu, concedendo-lhe a benesse, motivo pelo qual reconheço a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006, visto que estão presentes os requisitos legais, pois o réu é primário, não ostenta Maus antecedentes e não há provas nos autos de sua dedicação a atividades criminosas e nem que integre organização criminosa.

Discorrendo sobre os critérios para referida diminuição da pena, leciona Guilherme de Souza Nucci que "o legislador não estipulou quais seriam, apenas mencionando dever o magistrado reduzir a pena de um sexto a dois terços. cremos que, como sempre, deve o julgador pautar-se pelos elementos do art. 59 do Código Penal, com a especial atenção lançada pelo art. 42 desta Lei' (...) É lógico que há de existir o cuidado de evitar o bis in idem, ou seja, levarem conta duas vezes a mesma circunstância. Como temos defendido em outros trabalhos, as causas de diminuição de pena são mais relevantes que as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, de caráter nitidamente residual. Portanto, se o juiz notar um fator de destaque no crime cometido pelo traficante primário, de bons antecedentes, sem ligações criminosas, como a pequena quantidade da droga, deve utilizar esse critério diminuição da pena (ex : dois terços), deixando de considerá-la para a fixação da pena-base (a primeira etapa da aplicação da pena, conforme art. 68 do Código Penal). O contrário também se dá. Percebendo enorme quantidade de drogas, ainda que em poder de traficante primário, de bons antecedentes, sem outras ligações com o crime organizado, pode reservar tal circunstância para utilização na diminuição da pena (ex.. um sexto). Se assim o fizer, não se valerá da mesma circunstância por ocasião da eleição da pena-base, com fundamento no art. 59 do CP" (Leis penas e Processuais Penais Comentadas. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. p. 332/333).

Portanto, considerando a quantidade não impactante da substância entorpecente apreendida em poder do acusado, mas suficiente para se caracterizar hipótese

de tráfico, aplico o patamar de 2 /3 da diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11/343/2006, fixando-a definitivamente em 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e pagamento de 193 (cento e noventa e três) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da pena será o aberto (art. 33, 2.º, "c" e §3º., do Código Penal e HC 111.840/ES do STF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 14.06.2012 e HC 596.603 do STJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 08.09.2020 ), porque o réu é primário, não ostenta antecedentes criminais, pelo que as circunstâncias judiciais são favoráveis e foi afastado pela jurisprudência do STF e do STJ o caráter hediondo do tráfico privilegiado.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação, CONDENANDO o acusado GUSTAVO LEANDRO DOS SANTOS, a uma pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e pagamento de 193 (cento e noventa e três) dias-multa, calculados à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, como incurso no artigo 33, caput, c.c. Artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Considerando a redação do art. 44, §2.º, do Código Penal, bem como o decidido no HC 596.603 do STJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 08.09.2020, sendo a pena privativa de liberdade superior a um ano, a substituo por duas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e interdição temporária de direitos consistente em proibição de frequentar determinados lugares, a serem fixados pelo juízo da execução, que são as mais adequadas para reprimir a sua conduta.

A substituição por multa não foi aplicada, porque insuficiente para punir o crime e também diante da situação econômica do réu.

A pena restritiva de direitos terá a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída (art. 55 do Código Penal).

Sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade por outro crime o juiz da execução decidirá sobre a conversão (art. 44, §5.º, do Código Penal).

O réu poderá recorrer em liberdade.

Decreto a perda dos bens apreendidos em favor da União Federal.

Expeça-se o necessário.

Custas na forma da lei.

PIC

Limeira, 18 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA